

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER

A R R E S T

**nr. 242.138 van 24 juli 2018
in de zaak A. 225.625/XII-8580**

In zake: de cvba PRICE WATERHOUSE COOPERS ENTERPRISE
ADVISORY
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Neil Braeckevelt en Evelien Vanhauter
kantoor houdend te 8000 Brugge
Ezelstraat 25
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Frank Judo en Stijn Maeyaert
kantoor houdend te 1000 Brussel
Keizerslaan 3
bij wie woonplaats wordt gekozen

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 5 juli 2018, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van de Vlaamse overheid (Vlaamse Gewest), Departement Mobiliteit & Openbare werken van ongekende datum waarbij de offerte van [de cvba Price Waterhouse Coopers Enterprise Advisory] voor de opdracht voor diensten met betrekking tot ‘uitrol van een systeem van wegenheffing’ (Bestek nr. AB/2017/13) onregelmatig is bevonden en werd geweerd”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 20 juli 2018, om 11.00 uur.

Staatsraad Johan Bovin heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Evelien Vanhauter en Neil Braeckevelt, die verschijnen voor de verzoekende partij, en advocaten Stijn Maeyaert en Nicolas Goethals, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor diensten betreffende “een geïntegreerde consultancyopdracht voor de uitrol van een systeem van wegenheffing”.

De aankondiging van deze opdracht wordt gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen op 9 februari 2018 en in het Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie op 13 februari 2018.

De opdracht betreft vier aspecten met betrekking tot de mogelijke invoering van een systeem van wegenheffing, met name “1° de technische aspecten; 2° de financieel-boekhoudkundige aspecten; 3° de juridische aspecten en 4° participatie, communicatie en draagvlakvorming”.

3.2. De plaatsing van de opdracht gebeurt bij wijze van openbare procedure.

Het bestek bevat - naast een vast gedeelte - ook een voorwaardelijk gedeelte, dit is onderdeel 5, dat de eventuele uitbreiding van het onderzoek naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat.

3.3. Wat de uitsluitings- en selectiecriteria betreft legt het bestek het voorleggen van het zogenaamd Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) verplicht op. De inschrijver moet op het UEA verklaren of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. Enkel de gevraagde referenties moeten worden toegevoegd; attesten en andere voor te leggen stukken kunnen achteraf bijkomend worden opgevraagd door de aanbestedende overheid.

3.4. De uiterste datum voor de indiening van de offertes is 23 maart 2018.

Twee ondernemingen dienen een offerte in, namelijk de verzoekende partij en (een consortium rond) KPMG. Dit gebeurt telkens via het e-Tendering platform, zoals opgelegd in het bestek.

3.5. Met een aangetekend schrijven gedateerd op 21 juni 2018 wordt de verzoekende partij er van in kennis gesteld dat de verwerende partij haar offerte voor de opdracht als substantieel onregelmatig heeft geweerd.

In bijlage wordt een uittreksel van de gunningsbeslissing gevoegd, met de volgende motivering:

“C. Onderzoek en beoordeling offertes

C.1 Controle uitsluitingsgrond in verband met fiscale en sociale schulden, incl. eventuele corrigerende maatregelen

[...]

PWC

[...]

De inschrijver diende voor de 5 onderaannemers het UEA in, voor PWC zelf werd echter geen UEA toegevoegd.

[...]

C.2 voorlopige controle van de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en van de selectiecriteria op basis van het UEA, incl. eventuele corrigerende maatregelen

[...]

PWC

PWC zelf diende, zoals hoger aangegeven, geen UEA in. De offerte bevat ook niet alle benodigde documenten die toelaten het ontbreken van het UEA te remediëren. Het ontbreken van het UEA voor PWC impliceert dat de betrokken offerte (cfr. artikel 76, §1 KB Plaatsing 2017) als substantieel onregelmatig wordt beschouwd en uit de verdere procedure wordt geweerd. Een substantieel onregelmatige offerte die in het kader van een openbare procedure werd ingediend, dient door de aanbestedende overheid (cfr. artikel 76, §3 KB Plaatsing 2017) immers nietig te worden verklaard. De Raad van State heeft zich overigens al in dezelfde zin uitgelaten, zie m.n. de arresten nr. 240.618 van 30 januari 2018 en nr. 240.748 van 20 februari 2018.

Facultatieve en verplichte uitsluitingsgevallen: wegens het ontbreken van het UEA kon aldus geen voorlopige controle op o.a. de eventuele corrigerende maatregelen (in geval een bepaalde uitsluitingsgrond werd aangevinkt) worden uitgevoerd. De opdracht zal uiteindelijk worden gegund aan KPMG.

[...]

Tussenbesluit: [...] De offerte van PWC wordt, wegens het ontbreken van het UEA, als substantieel onregelmatig aangemerkt en uit het verdere gunningsonderzoek geweerd.

C.3 onderzoek van de regelmatigheid van de offertes (zie art. 76 KB Plaatsing)

PWC

Zoals hoger aangegeven, werd de offerte van PWC als substantieel onregelmatig beschouwd wegens het ontbreken van het UEA. De offerte van deze inschrijver wordt dan ook niet toegelaten tot de verdere fases van het gunningsonderzoek.

[...]

Niettemin wordt – louter ter informatie en zonder dat hieruit kan worden afgeleid dat deze offerte alsnog als ‘voorlopig geselecteerd’ werd aanzien – hieronder meegegeven dat de beschouwd offerte ook met andere substantiële onregelmatigheden lijkt te zijn behept.

Het gaat met name om de vaststelling dat het aantal bladzijden dat ingevolge het bestek mag gewijd worden aan de inhoudelijke toelichting van de Werkpakketten regelmatig werd overschreden (bv onderdeel 1 – WP1, WP2; onderdeel 2 – WP1, WP2, WP5, e.a.) waardoor de vergelijkbaarheid van de inschrijvers in het gedrang komt: een inschrijver die zich houdt aan het voorgeschreven aantal bladzijden bevindt zich aldus in een nadelige positie aangezien hij zijn beschrijving van zijn plan van aanpak minder gedetailleerd naar voor kan brengen t.a.v. de aanbestedende overheid.

[...]”.

Dit is de bestreden beslissing.

IV. Schorsingsvoorwaarden

4.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement *prima facie* kan verantwoorden en dat een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van de gewone vordering tot schorsing.

4.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ van toepassing.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid.

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen verantwoorden.

V. Onderzoek van het enig middel

Uiteenzetting van het middel

5.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten’ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016), artikel 73, § 1, laatste lid, van dezelfde

‡CEHSNBGCD-BDEEIV‡

wet en “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het proportionaliteitsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het mededingingsbeginsel, de (materiële en formele) motiveringsplicht (zoals die onder meer volgt uit artikel 4 en 5, 8°, van de rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 en artikel 2 en 3 van de formele motiveringswet, alsook het zorgvuldigheidsbeginsel.”

De verzoekende partij acht deze bepalingen en beginselen geschonden doordat:

“verwerende partij de offerte van verzoekende partij heeft geweerd omwille van het ontbreken van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), en

Doordat: verwerende partij daarbij verwijst naar artikel 76 §1 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (‘KB Plaatsing 2017’) en artikel 76 §3 KB Plaatsing 2017, alsook naar rechtspraak van Uw Raad (arresten nr. 240.618 van 30 januari 2018 en nr. 240.748 van 20 februari 2018), om de gebrekkige indiening of het ontbreken van het UEA als substantiële onregelmatigheid te beschouwen, en

Doordat: in de bestreden beslissing ook wordt opgemerkt dat de offerte niet alle benodigde documenten bevat die toelaten om het ontbreken van het UEA te remediëren, zonder verdere verduidelijking van de documenten die de aanbestedende overheid in dit verband bedoelt of viseert,

Terwijl: artikel 4, eerste lid Overheidsopdrachtenwet 2016 vereist dat de aanbesteder onder meer op proportionele wijze moet handelen, en

Terwijl: artikel 73 §1, laatste lid Overheidsopdrachtenwet 2016 toelaat dat een ondernemer een UEA dat reeds in een vorige overheidsopdracht werd gebruikt, opnieuw gebruikt, en

Terwijl: Uw Raad in zijn arrest nr. 241.265 van 19 april 2018 al oordeelde dat in geval van een gebrekkige indiening van het UEA-formulier de aanbestedende overheid de perken van de redelijkheid overschrijdt door dergelijke offerte zonder meer als substantieel onregelmatig te weren en dat de omgang met het UEA-formulier niet op al te rigide wijze mag worden opgevat, en

Terwijl: verzoekende partij als inschrijver wel degelijk, net zoals voor haar onderaannemers, een UEA-formulier op het elektronisch platform had opgeladen, maar een aantal documenten en UEA-formulieren werden ingetrokken en opnieuw opgeladen, waarbij er iets is fout gelopen bij het opnieuw opladen van het UEA-formulier van verzoekende partij zelf (hetgeen ook duidelijk blijkt uit de gegevens van het indieningsrapport en dus aan verwerende partij bekend was), en

Terwijl: de bewijsmiddelen voor de beoordeling van de selectievereisten (financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid) ook al meteen bij de offerte waren gevoegd en een beoordeling op dat vlak door de aanbestedende overheid toelieten, en

Terwijl: verzoekende partij bovendien eerder al voor een opdracht van hetzelfde departement van verwerende partij een UEA had ingediend waaruit bleek dat zij zich in geen enkel geval bevond dat de uitsluiting met zich kon meebrengen, en

Terwijl: van een zorgvuldige en proportioneel handelende overheid in alle redelijkheid kan worden verwacht dat zij in de gegeven omstandigheden de inschrijver bevraagt omtrent de indiening van het UEA teneinde een eventueel gebrek alsnog te laten remediëren, en

Terwijl: verwerende partij zelf een controle uitvoerde op vlak van attesten inzake sociale zekerheid en belastingen via Telemarc, al is niet duidelijk of zij dit op zorgvuldige wijze ook in hoofde van verzoekende partij heeft gedaan

Terwijl: het UEA als finaliteit een versoepeling voor de inschrijvers en een verhoging van de mededinging beoogt en het dus niet als een nieuwe substantiële regelmatigheidsvereiste kan worden toegepast waardoor de mededinging wordt beknot eerder dan bevorderd (in tegenstelling tot de vorige regelgeving), en

Terwijl: een te rigide interpretatie van de artikelen 76 §1 KB Plaatsing 2017 en artikel 76 §3 KB Plaatsing 2017 die erop neerkomt dat bij gebrekkige indiening of ontbreken van het UEA in het kader van een openbare procedure in alle omstandigheden de aanbesteder verplicht is om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen, zelf in strijd is met de voormelde rechtsregels- en beginselen; in voorkomend geval dienen deze bepalingen op grond van artikel 159 G.W. als onwettig buiten toepassing te worden beschouwd, en

Terwijl: verwerende partij ook zelf lijkt aan te geven dat er een mogelijkheid tot remediëring in geval van problemen met het UEA bestaat, maar zij vervolgens – en enigszins tegenstrijdig - toch zonder verdere motivering in het licht van bovenvermelde beginselen tot de substantiële onregelmatigheid van de offerte van verzoekende partij besluit, en

Terwijl: artikel 5, 8° van de rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 met betrekking tot de motivering van de beslissing tot wering van een inschrijver wiens offerte als onregelmatig wordt bevonden vereist dat die beslissing de juridische en feitelijke motieven voor de wering bevat en dat die met name betrekking hebben op het abnormale karakter van de prijzen en, in voorkomend geval, op het bevinden van de niet gelijkwaardigheid van de voorgestelde oplossingen aan de technische specificaties of het niet voldoen aan de vastgestelde prestatie-eisen of functionele eisen; dat in casu geen van dergelijk motief aan de orde is, doch enkel een vage en tegenstrijdige grond wordt ingeroepen

Zodat: verwerende partij een onredelijke, onzorgvuldige en dispropor-tionele beslissing heeft genomen zonder bovendien rekening te houden met reeds beschikbare gegevens en documenten, met een tegenstrijdige motivering en aldus de ingeroepen rechtsregels en beginselen heeft geschonden”.

Beoordeling

5.2. Artikel 4, eerste lid, van de wet overheidsopdrachten 2016, bepaalt:

“De aanbesteders behandelen de ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelen op een transparante en proportionele wijze”.

In de memorie van toelichting bij het ontwerp dat uiteindelijk de voormelde wet overheidsopdrachten 2016 is geworden, is te lezen:

“Dit artikel bevestigt de beginselen van gelijke behandeling, het discriminatieverbod, het transparantie- en het proportionaliteitsbeginsel. Het eerste lid stemt overeen met artikel 5 van de wet van 15 juni 2006, weze het dat, in navolging van artikel 18 van richtlijn 2014/24/EU en artikel 36 van richtlijn 2014/25/EU, nu ook het proportionaliteitsbeginsel wordt vermeld”.

Artikel 18, lid 1, van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 ‘betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG’, waarnaar in de memorie van toelichting wordt verwezen, luidt:

“Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelen op een transparante en proportionele wijze”.

In het verslag van de Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting over het ontwerp dat de wet overheidsopdrachten 2016 is geworden, is te lezen:

“De minister preciseert dat het proportionaliteitsbeginsel voor het eerst voortaan wordt uitdrukkelijk vermeld in artikel 4. Het Hof van Justitie hanteert dat proportionaliteitsbeginsel al bij de interpretatie van de Europese regelgeving. De vermelding in artikel 4 is daarvan de weerspiegeling. Zo zullen de aanbestedende overheden, wanneer zij facultatieve uitsluitingsgronden hanteren, bijzondere aandacht moeten schenken aan het proportionaliteitsbeginsel. Om die reden mogen kleine

onregelmatigheden alleen in uitzonderlijke omstandigheden tot de uitsluiting van een ondernemer leiden. Mochten dergelijke kleine onregelmatigheden zich echter geregeld voordoen, zou zulks twijfels doen rijzen over de betrouwbaarheid van de ondernemer en een reden tot uitsluiting kunnen zijn”.

5.3. Artikel 73 van de wet overheidsopdrachten 2016, bepaalt:

“§ 1. Op het ogenblik van de indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes, naargelang het geval, leggen de kandidaten of inschrijvers, het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken kandidaat of inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :

1° hij bevindt zich niet in een van de situaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69, waardoor kandidaten of inschrijvers kunnen of moeten worden uitgesloten;

2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71;

3° hij voldoet, indien van toepassing, aan de objectieve regels en criteria voor de beperking van het aantal kandidaten, als vastgesteld overeenkomstig artikel 79.

Indien de ondernemer overeenkomstig artikel 78 een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten bevat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ook de in het eerste lid genoemde gegevens ten aanzien van die entiteiten.

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bestaat uit een formele verklaring van de ondernemer dat de betrokken grond tot uitsluiting niet van toepassing is en/of dat aan het selectie criterium is voldaan en bevat de relevante informatie die door de aanbestedende overheid wordt verlangd. Voorts vermeldt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument welke overheidsinstantie of derde verantwoordelijk is voor het vaststellen van de bewijsstukken en bevat zij een formele verklaring dat de ondernemer in staat zal zijn om op verzoek en onverwijld die bewijsstukken te leveren.

Indien de aanbestedende overheid het bewijsstuk rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een databank conform de vierde paragraaf, bevat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ook de daartoe vereiste informatie, zoals het internetadres van de databank, alle identificatiegegevens en, in voorkomend geval, de benodigde verklaring van instemming.

Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachten-procedure gebruikte Uniform Europees Aanbestedingsdocument opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.

§ 2. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt opgesteld op basis van het door de Europese Commissie vast te stellen model en wordt uitsluitend in elektronische vorm verstrekt.

§ 3. De aanbestedende overheid kan kandidaten en inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Behoudens voor opdrachten die zijn gebaseerd op overeenkomstig artikel 43, § 4 of § 5, 1°, geplaatste raamovereenkomsten, verzoekt de aanbestedende overheid vóór de gunning van de opdracht, de inschrijver aan wie zij heeft besloten de opdracht te gunnen, de actuele ondersteunende documenten over te leggen, als bedoeld in artikel 75. De aanbestedende overheid kan ondernemers verzoeken de ontvangen certificaten aan te vullen of te verduidelijken.

§ 4. Niettegenstaande paragraaf 3 zijn de ondernemers niet verplicht ondersteunende documenten of andere bewijsstukken over te leggen indien en voor zover de aanbestedende overheid de certificaten of de relevante informatie rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een gratis toegankelijke nationale databank in elke lidstaat, zoals een nationaal aanbestedingsregister, een digitaal bedrijfsdossier, een systeem voor digitale documentopslag of een voorselectiesysteem.

Niettegenstaande paragraaf 3 zijn de ondernemers niet verplicht ondersteunende documenten over te leggen wanneer de aanbestedende overheid deze documenten reeds in haar bezit heeft ten gevolge van een opdracht of raamovereenkomst die eerder werd afgesloten. Dit op voorwaarde dat de betrokken ondernemers in hun aanvraag tot deelneming of in hun offerte de procedure identificeren tijdens dewelke zij deze documenten reeds hebben voorgelegd en voor zover de voormelde inlichtingen en documenten nog beantwoorden aan de gestelde vereisten”.

Artikel 38 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’ (hierna: het koninklijk besluit plaatsing 2017), bepaalt:

“§ 1. Op het ogenblik van de indiening van de aanvragen tot deelneming en/of van de offertes leggen de kandidaten of inschrijvers, overeenkomstig artikel 73 van de wet, het UEA voor, tenzij in de gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in de in artikel 42, § 1, 1°, b) en d), 2°, 3°, 4°, b), en c), van de wet, bedoelde gevallen.

De aanbestedende overheid verschaft in de aankondiging van opdracht of in de opdrachtdocumenten waarnaar deze aankondiging verwijst de richtsnoeren die toelaten het UEA in te vullen. Met name geeft hij aan welke de werkwijze is overeenkomstig paragraaf 2.

[...]

§ 2. Wat deel IV van het UEA betreft, kan de aanbestedende overheid naar keuze beslissen :

1° om de ondernemers te verzoeken om precieze inlichtingen op te geven door middel van het invullen van de afdelingen A tot D; of

2° de gevraagde inlichtingen beperken tot de vraag of de ondernemer al dan niet voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria, overeenkomstig de afdeling ‘Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria’. In dat geval moet alleen deze afdeling ingevuld worden.

Voor de in bijlage III van de wet opgesomde sociale en andere specifieke diensten, moet de aanbestedende overheid echter steeds de mogelijkheid geven aan de ondernemer om op globale wijze kenbaar te maken dat hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria, overeenkomstig het eerste lid, 2°.

§ 3. Het onderhavige artikel is slechts van toepassing op de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking”.

5.4. Het bestek dat de opdracht beheerst, bepaalt:

“De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Zie A.1.4. voor meer informatie over het UEA”.

Tevens bepaalt het bestek:

“De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria.

Er wordt gevraagd de gevraagde referenties reeds toe te voegen. Attesten kunnen achteraf bijkomend worden opgevraagd. De voor te leggen stukken dienen niet aan het UEA te worden toegevoegd maar zal de aanbestedende overheid later opvragen indien noodzakelijk. Zie A.1.4. voor meer informatie over het UEA”.

In dat deel A.1.4 is opgenomen:

“De inschrijver legt overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is (zie A.1.1.) en dat de inschrijver voldoet aan de selectiecriteria (zie A.1.2.).

Voor de opmaak van het UEA kan de inschrijver gebruik maken van het model dat mee opgeladen werd bij de opdrachtdocumenten op e-Notification.

Voor wat betreft deel IV van het UEA moet de inschrijver louter verklaren dat hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.

De inschrijver moet tevens:

- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als inschrijver, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet (zie A.1.3.);
- in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B van het UEA;

De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure ten allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure”.

Inzake de vorm en inhoud van de offerte wordt in het bestek bepaald:

“Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier en de inventaris, bij de offerte gevoegd moeten worden:

- ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de inschrijver (A.1.4.);
- verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet in het kader van het voldoen aan de selectiecriteria (A.1.3.);
- ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver zich beroept, en voor alle deelnemers aan de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid;
- de nodige documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de personen die een elektronische handtekening plaatsen om de onderneming te verbinden (A.3.3.);
- gevraagde documenten in het kader van de selectie (A.1.2);
- de documenten in het kader van de beoordeling op basis van de gunningscriteria (A.5)”.

5.5. Artikel 76, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit plaatsing 2017, bepaalt:

“De volgende onregelmatigheden worden met name als substantieel beschouwd :

[...]

2° de niet-naleving van de vereisten bedoeld in de artikelen 38, 42, 43, § 1, 44, 48, § 2, eerste lid, 54, § 2, 55, 83 en 92 van dit besluit en in artikel 14

van de wet, voor zover zij verplichtingen bevatten ten aanzien van de inschrijvers; [...]”.

Artikel 76, § 3, van het koninklijk besluit plaatsing 2017, bepaalt:

“Wanneer gebruik wordt gemaakt van een openbare of niet-openbare procedure, verklaart de aanbestedende overheid de substantieel onregelmatige offerte nietig. [...]”.

In het verslag aan de Koning wordt inzake die bepaling verduidelijkt:

“In geval van een substantiële onregelmatigheid, moet de offerte steeds nietig worden verklaard en beschikt de aanbestedende overheid over geen enkele beoordelingsruimte”.

5.6. De verzoekende partij erkent dat zij het verplichte – het wordt niet betwist dat de waarde van de voorliggende opdracht de drempel voor de Europese bekendmaking overschrijdt – Uniform Europees Aanbestedingsdocument (hierna: UEA) niet heeft voorgelegd. Enkel de UEA's van haar onderaannemers werden ingediend.

5.7. In zoverre de verzoekende partij verwijst naar het arrest nr. 240.618 van 30 januari 2018 dient te worden vastgesteld dat in die zaak de verzoekende partij wel een UEA bij de inschrijving had gevoegd maar op gebrekkige wijze, namelijk onvolledig, daar waar in de voorliggende zaak de verzoekende partij geen UEA heeft neergelegd, hetgeen zij overigens niet betwist. Het voormelde arrest, dat aldus betrekking heeft op een andere casus dan de voorliggende, overweegt overigens ook dat de affirmaties van de verwerende partij, namelijk de verwijzing naar artikel 38 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, dat de verplichting bevat tot het voorleggen van het UEA en naar artikel 76, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit, dat het niet-naleven van dat vereiste als substantieel beschouwt, lijken te kunnen worden bijgevalen in hun algemeenheid, en aldus lijken te kunnen gelden in de gevallen waarbij een UEA ontbreekt.

5.8. Artikel 38, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 legt op dat bij opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking, het UEA “overeenkomstig artikel 73 van de wet” wordt voorgelegd. De doelstelling van het UEA – administratieve vereenvoudiging zoals omschreven in overweging 84 van de Richtlijn 2014/24 – verhindert niet dat de verplichting die tot stand kwam met het oog op die doelstelling en in de op de zaak toepasselijke wet- en regelgeving is opgenomen, wel moet worden nageleefd. De opportuniteit van het UEA lijkt alvast geen discussiepunt dat voor de Raad van State kan worden gebracht.

5.9. De motivering in het gunningsverslag stelt:

“PWC zelf diende, zoals hoger aangegeven, geen UEA in. De offerte bevat ook niet alle benodigde documenten die toelaten het ontbreken van het UEA te remediëren. Het ontbreken van het UEA voor PWC impliceert dat de betrokken offerte (cfr. artikel 76, §1 KB Plaatsing 2017) als substantieel onregelmatig wordt beschouwd en uit de verdere procedure wordt geweerd. Een substantieel onregelmatige offerte die in het kader van een openbare procedure werd ingediend, dient door de aanbestedende overheid (cfr. artikel 76, §3 KB Plaatsing 2017) immers nietig te worden verklaard. De Raad van State heeft zich overigens al in dezelfde zin uitgelaten, zie m.n. de arresten nr. 240.618 van 30 januari 2018 en nr. 240.748 van 20 februari 2018”.

Zoals uit het verzoekschrift blijkt heeft de verzoekende partij de voormelde verwijzing in het gunningsverslag terecht begrepen als een verwijzing naar artikel 76, § 1, vierde lid, 2°, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 en is zij zich bewust van de verwijzing in die bepaling naar artikel 38 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, dat het UEA betreft.

5.10. De omstandigheid dat de verzoekende partij wel UEA's voor haar onderaannemers heeft ingediend, is niet relevant; het bestek legt op dat de inschrijver zelf (ook) een UEA indient teneinde aan te tonen dat hij voldoet aan onder meer de selectiecriteria. Het is ook niet vereist dat de sanctie bij het niet indienen van een UEA wordt herhaald in het bestek.

5.11. De verzoekende partij betoogt voorts dat zij reeds eerder voor een overheidsopdracht van dezelfde aanbestedende overheid - zelfs hetzelfde

departement - recent ook al een aanvaard UEA-formulier had ingediend, waaruit bleek dat er zich in hoofde van de verzoekende partij “geen enkel probleem stelde op vlak van uitsluitingscriteria”. De verwerende partij was dus reeds in het bezit van een recent ingevuld UEA-formulier van de verzoekende partij.

Artikel 73, § 1, *in fine*, van de wet overheidsopdrachten 2016 bepaalt:

“Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachten-procedure gebruikte Uniform Europees Aanbestedingsdocument opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn”.

In de memorie van toelichting is ter zake te lezen:

“In het laatste lid van de eerste paragraaf wordt vervolgens gesteld dat de reeds in een vorige gunningsprocedure gebruikte UEA’s opnieuw mogen worden aangewend, mits wordt bevestigd dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn. Natuurlijk is deze werkwijze slechts werkbaar indien het eerder gebruikte UEA ook inlichtingen biedt omtrent de in concreto door de aanbestedende overheid verlangde informatie. De mogelijkheid om bepaalde concrete informatie te bekomen via het UEA primeert aldus boven de regel dat, indien mogelijk, het UEA hergebruikt mag worden”.

De opdracht ‘Opmaak en procesbegeleiding van het Routeplan 2030 voor de vervoerregio Antwerpen’ (Besteknummer AB/2017/09) waarvoor de verzoekende partij eerder een UEA had ingediend, legt op:

“De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn: Solvabel zijn. De solvabiliteit wordt aangetoond d.m.v. een passende bankverklaring opgemaakt volgens de bijlage 11 bij het KB Plaatsing”.

Het bestek dat van toepassing is op de voorliggende opdracht, bepaalt inzake de economische en financiële draagkracht:

De inschrijver dient cumulatief te voldoen aan de hieronder gestelde minimumeisen inzake financieel-economische draagkracht wat betreft:

- a) verzekering tegen beroepsrisico;
- b) minimale omzet.

a) Verzekering tegen beroepsrisico

De inschrijver moet gedurende de ganse duur van het project over een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid beschikken met een globale dekking van minstens 15.000.000 Euro. De inschrijver toont aan te beschikken over een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid ten belope van dit bedrag. De inschrijver mag zijn beroepsaansprakelijkheid ook verzekeren in een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die specifiek voor deze opdracht zal worden afgesloten indien de opdracht aan de inschrijver wordt toegewezen. De inschrijver voegt dan de nodige verklaringen toe van de verzekeraar of de makelaar. In geval van een specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor deze opdracht, voegen zij een bindende bevestigingsbrief toe van de makelaar en/of de verzekeraar waarin wordt bevestigd dat de verzekering zal worden afgesloten indien de opdracht aan de inschrijver wordt toegewezen. Deze verklaringen moeten in het Nederlands zijn opgesteld; geldig zijn én mogen maximaal drie maanden oud zijn. Indien de verklaring in een andere taal is opgesteld, wordt een beëdigde vertaling toegevoegd.

b) minimale omzet

De inschrijver behaalt een minimale omzet in de volgende domeinen:

- juridische dienstverlening: minimaal 260.000 Euro omzet;
- communicatie: minimaal 400.000 Euro omzet;
- ICT: minimaal 188.000 Euro omzet;
- Financieel-economische studies: minimaal 500.000 Euro omzet

De in concreto door de aanbestedende overheid verlangde informatie blijkt te dezen dan ook niet overeen te komen met die van het eerder gebruikte UEA. Een verwijzing naar dat eerder gebruikte UEA - de ingediende offerte lijkt overigens ook geen bevestiging te bevatten dat de in het eerder ingediende UEA-formulier opgenomen gegevens nog steeds correct zijn zoals vereist door artikel 73, § 1, *in fine*, van de wet overheidsopdrachten 2016 - lijkt bijgevolg het niet indienen van een UEA in de huidige opdracht niet te kunnen verhelpen, nu de eerder verstrekte informatie te dezen op het eerste gezicht niet lijkt te kunnen volstaan.

5.12. De verzoekende partij vraagt voorts dat artikel 76, § 1, vierde lid, 2°, en artikel 76, § 3, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing worden gelaten wegens strijdigheid “met artikel 4 Overheidsopdrachtenwet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het zorgvuldigheids-, het redelijkheids-, het mededingings- en het proportionaliteitsbeginsel”.

Artikel 159 van de Grondwet bepaalt:

“De hoven en rechtbanken passen de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.”

Uit het hiervoor onder randnummer 5.3. aangehaalde artikel 4, eerste lid, van de wet overheidsopdrachten 2016 en haar parlementaire voorbereiding, blijkt op het eerste gezicht niet dat die bepaling de substantiële onregelmatigheid annihileert.

Het niet-voorleggen van het vereiste UEA betreft immers geen facultatieve uitsluitingsgrond, maar wel een substantiële onregelmatigheid, waardoor voormeld artikel 4, eerste lid, geen mogelijkheid biedt om te ontkomen aan de sanctie die kleeft aan een offerte die met een substantiële onregelmatigheid is behept, ook niet als de opdracht een waarde heeft van enkele miljoenen euro's, er een beperkt aantal inschrijvingen was en enorm veel werk is gestoken in de voorbereiding van de offerte zoals het apologetisch luidt bij de verzoekende partij. De interpretatie die de verzoekende partij geeft aan artikel 4, eerste lid, van de wet overheidsopdrachten 2016 – die het onderscheid tussen de substantiële en niet-substantiële onregelmatigheid zou doen vervluchtigen – lijkt dan ook niet te kunnen worden bijgevalen.

Evenmin kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur op het eerste gezicht worden beschouwd als “wetten” in de zin van artikel 159 van de Grondwet. Een beroep op de toepassing van dat grondwetsartikel lijkt op grond daarvan dan ook uitgesloten.

5.13. Het komt volgens het bestek aan de inschrijver toe op het UEA te verklaren of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. Er wordt gevraagd de gevraagde referenties reeds toe te voegen. Attesten kunnen achteraf bijkomend worden opgevraagd. De voor te leggen stukken dienen niet aan het UEA te worden toegevoegd maar zal de aanbestedende overheid later opvragen indien noodzakelijk.

Het voormelde artikel 73, § 1, eerste lid, van de wet overheidsopdrachten 2016, bepaalt uitdrukkelijk dat “op het ogenblik van de

indiening” van de aanvragen tot deelneming of de offertes, naargelang het geval, de kandidaten of inschrijvers het door hen ingevulde UEA voorleggen. In uitvoering van deze bepaling schrijft artikel 38 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 voor dat het UEA “op het ogenblik van de indiening van de aanvragen tot deelneming en/of van de offertes [...] overeenkomstig artikel 73 van de wet” wordt voorgelegd.

Het feit dat de verzoekende partij de bewijsmiddelen voor de beoordeling van de selectievereisten al meteen bij de offerte had gevoegd zoals zij betoogt, en een beoordeling op dat vlak door de aanbestedende overheid toelieten, lijkt dan ook het voorleggen van het UEA op het ogenblik van de indiening van de offerte niet te kunnen vervangen. De overweging in het gunningsverslag dat de “offerte [...] ook niet alle benodigde documenten [bevat] die toelaten het ontbreken van het UEA te remediëren” lijkt dan ook de bestreden beslissing niet te kunnen vitiëren.

5.14. De verzoekende partij betoogt ten slotte dat er problemen waren op het elektronische e-Tendering platform. In tegenstelling tot de feitelijke situatie in de zaak die heeft geleid tot het arrest nr. 240.186 van 14 december 2017, waarnaar de verzoekende partij verwijst, heeft zij de verwerende partij niet op de hoogte gebracht van eventuele problemen bij de elektronische indiening van de offerte. Te dezen beweert de verzoekende partij slechts voor het eerst in het verzoekschrift dat er problemen waren met de e-Tenderingmodule. Het kan de verwerende partij dan ook niet worden verweten dat zij “[i]n die omstandigheden” niet heeft nagegaan of er zich problemen hebben voorgedaan op het elektronische e-Tendering platform.

Overigens verwerft met de indiening en vervolgens de intrekking van een UEA op het e-Tendering platform, de betrokken inschrijver geen recht om van de aanbestedende overheid te eisen dat zij na de opening van de offertes die inschrijver een UEA laat indienen. De verzoekende partij kon trouwens zelf in het indieningsrapport vaststellen dat haar UEA door haar was ingetrokken. Desondanks heeft zij nagelaten de verwerende partij van enig euvel op de hoogte te brengen.

5.15. Gelet op het voornoemde lijkt de motivering opgenomen in het gunningsverslag niet gebrekkig. Voor zover in het verzoekschrift kritiek wordt uitgeoefend op de motivering met betrekking tot overige substantiële onregelmatigheden waarmee de offerte van de verzoekende partij “lijkt te zijn behept”, moet worden vastgesteld dat die kritiek alleszins betrekking heeft op overtollige motieven, omdat de substantiële onregelmatigheid wegens het niet hebben ingediend door de verzoekende partij van een UEA op het ogenblik van de indiening van haar offerte, stand lijkt te houden. Kritieken op overtollige motieven zijn niet dienstig.

5.16. Een schending van de in het middel ingeroepen bepalingen en beginselen lijkt niet aangetoond.

Het enige middel is niet ernstig.

VI. Besluit en kosten

6.1. Het enige middel is niet ernstig gebleken. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden verworpen.

6.2. De kosten van de vordering, bestaande uit het rolrecht en de bijdrage aan het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, evenals de door de verwerende partij gevraagde basisrechtsplegingsvergoeding van 700 euro, vallen ten laste van de verzoekende partij.

BESLISSING

1. De Raad van State verwerpt de vordering.

2. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 200 euro, een bijdrage van 20 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij.

3. Het door de eerste belanghebbende partij onverschuldigd betaalde rolrecht, begroot op 150 euro, dient haar te worden terugbetaald.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van vierentwintig juli tweeduizend achttien, door de Raad van State, XIIe vakantiekamer, samengesteld uit:

Johan Bovin,	staatsraad,
	waarnemend voorzitter,
bijgestaan door	
Joris Casneuf,	griffier.

De griffier

De voorzitter

Joris Casneuf

Johan Bovin